

1502408-93.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502408-93.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502408-93.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2330564/2021 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 21778616 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2937/21/110 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2330564 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

ALEXSSANDRO PEREIRA VIANA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

ALEXSSANDRO PEREIRA VIANA e PAULO ROGERIO JUSTINIANO, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, incisos II (escalada) e IV (concurso de agentes), do Código Penal, porque no dia 06 de dezembro de 2021, por volta das 03h49min, na Avenida Rosa Aizemberg, nº 569, bairro Independência, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios e conjunção de esforços, subtraíram, para proveito comum, durante o repouso noturno e mediante escalada, 02 janelas de

alumínio, avaliadas em aproximadamente (um mil reais), conforme auto de avaliação de págs. 17/18, de propriedade da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. Segundo o apurado, os acusados se ajustaram entre si para a prática de um crime de furto.

Então, na madrugada do dia 06 de dezembro de 2021, ambos se dirigiram à UPA Vila Rosa, local dos fatos, e aproveitando-se da aparente falta de vigilância no local, escalaram o muro da unidade de saúde e ali ingressaram.

Em seguida, ambos retiraram duas janelas de alumínio do edifício, pularam o muro de volta à via pública, colocaram os objetos subtraídos no interior de um carrinho que possuíam e se evadiram do local.

Ocorre que a Guarda Municipal foi acionada e compareceu ao local. Em diligências pela rua da unidade hospitalar, os guardas avistaram os acusados empurrando o carrinho com as janelas furtadas em seu interior, razão pela qual procederam à abordagem de ambos.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse de ALEXSSANDRO e PAULO. Indagados acerca da origem dos bens que transportavam, ambos confessaram a prática delitiva, informando que pretendiam vender as janelas de alumínio em um "ferro velho".

Nessas circunstâncias, ambos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Acompanhada por inquérito policial (págs.04/63), a denúncia foi recebida (págs.69/71). Regularmente citados (págs. 149 e 152), os réus apresentaram respostas à acusação (págs. 156). Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.157/158), em instrução foram ouvidos o representante da Municipalidade e duas testemunhas comuns, interrogando-se os réus.

Em debates, a acusação requer a condenação dos acusados nos termos da denúncia; ao passo que a defesa postula a por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou o afastamento da qualificadora da escalada e da causa de aumento do repouso noturno.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do crime de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes, não havendo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade do delito está demonstrada nos autos de exibição, apreensão e entrega de págs. 16 (janelas de alumínio) e de avaliação a págs. 17/18, bem como no laudo pericial de págs. 72/74 (local dos fatos).

Quanto à autoria, nas duas fases da persecução penal os acusados admitiram a posse das janelas de alumínio. Todavia, ofertaram versão diversa da fase policial.

Na Delegacia de Polícia, os réus admitiram a escalada do muro, o ingresso no imóvel e a subtração das janelas de alumínio para venda em 'ferro-velho' (págs.11 e 12).

Em Juízo, embora tenham admitido a posse das esquadrias das janelas de alumínio, afirmaram que ingressaram no local porque o portão estava aberto. Não houve escalada. O material estava jogado no chão e acreditaram que nada ilícito praticavam, apoderando-se dos bens porque trabalham com reciclagem e precisam sustentar a família.

Alexssandro ainda acrescentou, também buscando afastar o dolo, que ali inicialmente ingressaram apenas para usar crack. A justificativa, todavia, foi afastada nas declarações do próprio corréu. Paulo Sérgio afirmou que os agentes não tinham usado substância entorpecente naquela madrugada e tampouco entraram no local para tal finalidade.

Fato é que o dolo de furto ficou evidenciado pelo mais da prova produzida em instrução.

O representante da Municipalidade Uiles Matos informou, em Juízo, que no imóvel onde os agentes ingressaram funcionou antiga Unidade Básica de Saúde. O Município de São Bernardo havia destinado o prédio à Secretaria de Educação, mas o local ainda não era utilizado. Permanecia, contudo, fechado (o que afasta a alegação dos agentes de que o portão estava aberto).

Foi acionado porque a Guarda Civil Municipal havia detido indivíduos na posse de

esquadrias de janelas de alumínio subtraídas do local, durante a madrugada. Nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o de furto, as declarações da vítima ou de seu representante legal, quando firmes e harmônicas, têm relevante valor probatório.

Se de um lado o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Confira-se:

[...] “Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima como espécie inculpada no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosas, o que se harmoniza ao caso em apreço”. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/04/2019).

Os guardas municipais Magda Molina e Ronaldo dos Santos Severo, em relato coeso e harmônico com o anterior, narraram os lances da diligência encetada na data dos fatos e esboçaram dúvida acerca do dolo e autoria:

No dia dos fatos, foram acionados pela Central da Guarda Civil Municipal informando que, por imagens de monitoramento, dois indivíduos tinham sido visualizados entrando na antiga UBS Vila Rosa. Posteriormente, teriam saído na posse de bens retirados do local, em um carrinho de mão. Para o delito, os furtadores teria, escalado muro lateral.

Os réus foram detidos nas imediações do local, de cem a trezentos metros depois, carregando as esquadrias das janelas de alumínio em carrinho de mão. As características eram semelhantes.

Inquiridos, os agentes admitiram a subtração dos bens.

O guarda municipal não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.1996 p. 39.846).

Os depoimentos dos guarda municipais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de segurança do patrimônio público para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a autoria.

O crime consumou-se.

Os acusados foram detidos em poder dos bens após percorrido considerável distância do local dos fatos (de cem a trezentos metros). O próprio acusado Paulo Sérgio declarou que já estavam 'bem longe' quando foram abordados.

O crime de furto consuma-se no momento da inversão da detenção em posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa subtraída, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, o que se vê patenteado na hipótese dos autos. Acrescenta-se que, embora prescindível, o objeto subtraído saiu da esfera de vigilância da vítima. É a teoria

da Amotio ou Aprehensio.

A respeito, vale menção a julgado recente do C. STJ, que esclarece qual o exato momento de consumação do crime em tela:

"HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOMENTO CONSUMATIVO.

PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO.

DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA

TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante. 2. Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se longo ou breve o espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada..." (STJ, Habeas Corpus HC 302820-DF, DJ 04/11/2014) - grifo nosso.

(...) Por fim, quanto ao momento consumativo do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o referido crime consuma-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa subtraída, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

(...) (HC 353.081/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

Não incide a figura do furto privilegiado (CP, art.155, §2º), pois os réus, reincidentes em crime patrimonial, não preenchem os requisitos legais.

Ao cabo da instrução, a qualificadora do concurso de agentes ficou comprovada.

A comparsaria entre os acusados vem evidenciada pela forma de atuação, ou seja, em conjunto, com plena aderência de vontades e divisão de tarefas, cada qual fazendo sua a ação do outro, sem oposição de qualquer obstáculo. Os acusados, previamente ajustados, ingressaram no imóvel da vítima e subtraíram as janelas do local.

Quanto à escalada, melhor sorte não assiste à acusação.

Com efeito, em Juízo (retratando-se da confissão policial) os réus negaram a escalada, fornecendo a inverossímil versão de que o portão da antiga UBS estava aberto. O representante legal da vítima afirmou que o imóvel permanecia fechado.

Outrossim, Uiles e o perito não relataram arrombamento do portão ou de outro obstáculo para acesso ao interior do imóvel. Dessa forma, foi necessário transpor muro ou gradil metálico na entrada.

Ocorre que, se de um lado não foi possível acolher a versão fornecida pelos agentes, de outro as demais provas carreadas aos autos não permitiram esclarecimento confiável acerca dos requisitos exigidos para o reconhecimento da qualificadora.

É irrefragável que a jurisprudência e a doutrina possuem entendimento consolidado pela necessidade do exame pericial nos casos de crimes não transeuntes (que deixam vestígios), conforme previsão do artigo 158 do Código de Processo Penal. A qualificadora da escalada, contudo, por se tratar de conduta que muitas vezes não deixa vestígios, pode se inserir na regra geral que admite ampla comprovação, vigorando o princípio do livre convencimento motivado (que pode ser, por exemplo, baseado na prova oral).

Todavia, na hipótese dos autos não ficou esclarecido se os agentes ingressaram pelo gradil metálico visualizado no laudo pericial de págs.72/74 (dois metros de altura, que aparentemente não apresenta esforço incomum para transposição) ou pelo muro lateral do imóvel, conforme dado fornecido pela testemunha Magda (a guarda municipal informou que o muro não é alto, sem mais detalhes).

A dúvida, não dirimida pela prova técnica ou oral, deve ser interpretada em favor dos agentes e afasta a circunstância que agrava a pena.

Configurada a causa de aumento de pena prevista no §1º, do artigo 155 do Código Penal.

O intuito da previsão é apenas mais severamente aquele que ataca o patrimônio desguarnecido, pois a vítima (inclusive estabelecimento comercial, representado por funcionários) e populares repousam. Os bens estão mais vulneráveis à incursão do agente porque as pessoas estão menos atentas.

No tocante ao horário de aplicação do repouso noturno, o Superior Tribunal de Justiça entende que este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e desperta para a vida cotidiana. Sendo assim, não há um horário prefixado. Atenta-se às características intrínsecas da vida cotidiana da localidade.

Na hipótese dos autos, o delito ocorreu por volta de 03h49min, em prédio de antiga Unidade Básica de Saúde, que se encontrava fechado e será destinado a uma escola. Não havia movimento na área. Incide a majorante.

Como anota Guilherme de Souza Nucci (in Código Penal Comentado, 18ª edição, Editora RT, p. 967): "A causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, porque anoiteceu. Se um imóvel é invadido durante a noite, estando ou não habitado, com ou sem moradores em seu interior repousando, o furto merece pena mais severa. É a solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se concentre no fato de haver maior perigo para a vítima que está em casa dormindo quando a subtração se realiza no mesmo local, o que não nos parece tenha sido objetivo da lei".

Quanto à aplicação da causa de aumento do furto noturno na hipótese de furto qualificado, recente entendimento do C. STJ reforça sua procedência:

"A causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do CP que se refere à prática do crime durante o repouso noturno é aplicável tanto na forma simples (caput) quanto na forma qualificada (§4º) do delito de furto. Isso porque esse entendimento está em consonância, mutatis mutandis, com a posição firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.193.194-MG, no qual se afigurou possível o reconhecimento do privilégio previsto no §2º do art. 155 do CP nos casos de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP), máxime se presentes os requisitos. Dessarte, nessa linha de raciocínio, não haveria justificativa plausível para se aplicar o § 2º do art. 155 do CP e deixar de impor o §1º do referido artigo, que, a propósito, compatibiliza-se com as qualificadoras previstas no §4º do dispositivo. Ademais, cumpre salientar que o §1º do art. 155 do CP refere-se à causa de aumento, tendo aplicação apenas na terceira fase da dosimetria, o que não revela qualquer prejuízo na realização da dosimetria da pena com arrimo no método trifásico. Cabe registrar que não se desconhece o entendimento da Quinta Turma do STJ segundo o qual somente será cabível aplicação da mencionada causa de aumento quando o crime for perpetrado na sua forma simples (caput do art. 155). Todavia, o fato é que, após o entendimento exarado em 2011 no julgamento do EREsp 842.425-RS, no qual se evidenciou a possibilidade de aplicação do privilégio (§ 2º) no furto qualificado, não há razoabilidade em negar a incidência da causa de aumento (delito cometido durante o repouso noturno) na mesma situação em que presente a forma qualificada do crime de furto. Em outras palavras, uma vez que não mais se observa a ordem dos parágrafos para a aplicação da causa de diminuição (§ 2º), também não se considera essa ordem para imposição da causa de aumento (§ 1º)" (HC 306.450-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/12/2014, DJe 17/12/2014).

Entendimento diverso implicaria a não admissão do furto privilegiado às hipóteses qualificadas do referido delito, tendo em vista que a previsão de dito benefício também se encontra em parágrafo anterior.

Não é este, todavia, o direcionamento dos Tribunais Superiores.

No mesmo sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci (in Código Penal Comentado, 18ª edição, Editora RT, p. 964/965):

"Em redor do tipo básico (caput), giram várias circunstâncias, algumas gerando aumento de pena, outras, diminuição. As elevações são obtidas por meio de qualificadoras e causas de aumento; as diminuições, por meio de privilégios e causas de diminuição. (...) A qualificadora, quando presente, altera a faixa de fixação abstrata da pena (no caso do furto, pode-se alterá-la para dois a oito anos

e multa conforme §4º - ou para três a oito conforme §5º), somente se pode eleger uma faixa para a pena, logo, escolhe-se a mais grave: de três a oito anos. A circunstância remanescente, pertencente à outra qualificadora do §4º (por exemplo, rompimento de obstáculo), deve ser levada em conta na aplicação da pena-base, como circunstância judicial. Entretanto, a incidência concomitante de causas de aumento e de diminuição, previstas no mesmo tipo penal, podem (e devem) ser aplicadas umas sobre as outras. Por isso, se houver furto noturno, cometido por primário, com coisa de pouco valor, pode-se fazer incidir o §1º e 2º. Diante disso, presente apenas uma circunstância qualificadora do §4º (ilustrando, a escalada), além da causa de aumento de ter sido o crime cometido durante o repouso noturno, prevista no §1º, nada impede a aplicação de ambas. O juiz parte da faixa indicada pelo §4º, por conta da escalada, logo, dois a oito anos; fixa a pena-base, com fruto no art. 59 do CP; verifica se há agravantes ou atenuantes (arts. 61 a 65); finalmente, insere as causas de aumento, no caso, um terço a mais, por consideração ao §1º. (...) A posição da causa de aumento no tipo penal, bem como da qualificadora, é completamente indiferente, levando-se em conta o processo trifásico de aplicação da pena. Outras considerações, para não aplicar o aumento do §1º às formas qualificadas (§4º ou §5º, constituem pura política criminal, visando à menor apenação ao acusado, embora distante da técnica de individualização da pena".

Segundo o entendimento da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, não existe incompatibilidade entre a causa de aumento especial prevista no §1º e as qualificadoras do §4º, ambas do artigo 155 do Código Penal.

Quanto à alegação da defesa no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça afastou a majorante na hipótese de furto qualificado, observo que realmente no RECURSO ESPECIAL Nº 1.890.981 - SP (2020/0214043-3), a TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, apontou-o, assim como aos REspS nº 1.888.756/SP e 1.891.007/RJ, como representativos de controvérsia e candidatos à afetação, impondo aos feitos o rito estabelecido pelos arts. 256 ao 256-D do RISTJ.

A controvérsia suscitada foi assim identificada:

"- (im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Ocorre que ainda não foi publicada votação e tese, em sede de recurso repetitivo, de que a causa de aumento de pena prevista no §1º do artigo 155, do Código Penal, não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º).

Portanto, por ora, prevalece o entendimento deste Juízo.

A incidência, inclusive, veio afirmada em recente Acórdão do Tribunal Superior:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. COMPATIBILIDADE DA CAUSA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO COM O FURTO NOTURNO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. QUESTÃO JURÍDICA CLARAMENTE DELINEADA.

VIOLAÇÃO AO ART. 155, § 1º DO CP. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A matéria versada nos autos se refere à questão de direito, no tocante a incompatibilidade ou não, entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. Ausente, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ II - A causa de aumento do repouso noturno é aplicável no crime de furto, tanto na modalidade simples quanto na qualificada. Precedentes. Agravo regimental desprovido". (AgRg no REsp n. 1.990.699/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Finalmente, não se olvida a justificativa ofertada pelos acusados: Dificuldade financeira.

Ocorre que tal circunstância, por si só, não configura estado de necessidade. Há que se comprovar não apenas a miserabilidade, mas também que a conduta criminoso foi a derradeira para a sobrevivência do agente ou de sua família, sob pena de se acolher a prática criminoso como meio de vida. De tal ônus os réus não se desincumbiram a contento.

Inexiste nos autos prova da situação de extrema necessidade dos acusados, de que

agiram visando proteger-se de perigo atual e inevitável que não tenham dado causa, elementos mínimos necessários para acolhimento da excludente (CPP, art.156).

Nessa linha:

"(...) Nesse diapasão, a despeito da falta de oportunidade e da situação de penúria a que parte da população está submetida, esse fato não pode ser utilizado como justificativa de inocência para aquele que sucumbe à tentação do ganho fácil, por cupidez ou qualquer outro motivo, enveredando pelos caminhos tortuosos da vida criminosa. Reconhecendo essa conduta como excludente da ilicitude pela ausência de um dos seus elementos, além de precedente extremamente perigoso, traria total desesperança aos milhões de brasileiros, também desempregados, que pautam suas vidas pelos princípios da dignidade, ética e moralidade. Essas pessoas saem todos os dias de casa em busca da sobrevivência honesta, não se valendo do desespero como justificativa para a prática de delitos. Logo, o fato de estar alguém desempregado e passando por dificuldades não autoriza a afrontar o ordenamento jurídico, tampouco subsume-se à hipótese de estado de necessidade. Portanto, à míngua de qualquer prova do alegado, rejeita-se o argumento de defesa (...)" (TJSP Apelação Criminal nº 0001530-84.2017.8.26.0441, Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 08.04.2019).

"(...) A par disso, não se comprovou a impossibilidade, de acordo com as circunstâncias concretas, de o apelante atuar de acordo com o ordenamento jurídico, como sustenta a Defesa, não bastando a mera alegação de que estava "desesperado", pois tem um filho pequeno e o pagamento de suas contas de aluguel, água e luz estava atrasado, para justificar o sacrifício do bem jurídico em questão.

Em suma, era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu favor(...)" (TJSP Apelação Criminal nº 01508960-65.2020.8.26.0228, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Leme Garcia, j. 04.02.2021).

A declaração de ALEXSSANDRO de que os agentes são usuários de crack também não leva à absolvição.

Não há prova de que, durante a ação criminosa, os réus estavam sob efeito de substância entorpecente. Os guardas civis municipais afastaram esta circunstância. O corréu PAULO SÉRGIO ratificou os dizeres dos agentes da lei, afirmando que não tinham consumido droga.

Não obstante, ainda que a premissa fosse adotada como verdadeira, não teria o condão de afastar a culpabilidade dos réus.

Em Juízo, os acusados não apresentaram indicativo apto a revelar comprometimento da capacidade cognitiva em razão do uso de substância entorpecente. Pelo contrário, revelaram-se lúcidos, relatando a sua versão dos fatos de forma concatenada e segura. Não há relato de alteração comportamental ou de saúde, o que não se coaduna com o quadro de dependência química.

Conforme preceitua o art. 28, II, do CP, a embriaguez, voluntária ou culposa, ausente prova em sentido contrário, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. No referido dispositivo legal, o Estatuto Repressivo adotou a teoria da actio libera in causa, "segundo a qual, considera-se imputável quem se põe em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, seja dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime" (TJMG, AC1.0352.03.007518-3/001, Rel. Des^a MARIA CELESTE PORTO, DJ 24/2/2007).

Dessarte, os acusados realizaram conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhes a condenação e a pena que passo a dosar, eis que não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Analizados os fatores de individualização da pena, verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59 não são totalmente favoráveis ao réu PAULO SÉRGIO, que

ostenta duas condenações anteriores e irrecorríveis pelos delitos de roubo (autos nº 001401-89.2012.826.0161, 1ª Vara Criminal de Diadema. Trânsito em julgado em 29/07/2013. Pena extinta pelo cumprimento em 28/03/2017) e receptação (autos nº 0001523-95.2017.8.26.0537, 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 14/12/2017, cf. certidão criminal de págs. 30/34 e folha de antecedentes de págs. 35/44).

Assim, fixo a pena base de PAULO SÉRGIO acima do mínimo legal, elevando-a em 1/6, o que perfaz 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. A pena base de ALEXSSANDRO fica estabelecida no mínimo legal de 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Reincidentes (ALEXSSANDRO - furto qualificado - autos nº 1501880-30.2019.8.26.0537, 2ª Vara Criminal de Diadema. Trânsito em julgado em 30/01/2020, cf. certidão criminal de págs. 25/26 e folha de antecedentes de págs. 27/29. PAULO SÉRGIO - receptação e resistência - autos nº 0000210-02.2017.8.26.0537, 2ª Vara Criminal de Diadema. Trânsito em julgado em 06/03/2019, cf. certidão criminal de págs. 30/34 e folha de antecedentes de págs. 35/44), elevo a pena de cada réu em 1/6, fixando-a em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, para ALEXSSANDRO e 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa para PAULO SÉRGIO. Não incidem atenuantes (os réus afastaram o dolo de furto em Juízo).

O reconhecimento de antecedentes criminais na primeira e da reincidência na segunda etapa da dosimetria não configura bis in idem em relação a PAULO SÉRGIO, pois foram consideradas condenações distintas em cada etapa.

Neste sentido:

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem. O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência (HC n. 348.451/RJ, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/5/2016)" (AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2018, DJe 2/8/2018)" (AgRg no RESp 1816050/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/09/2019).

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de aumento do repouso noturno (CP, art.155, §1º). Elevo a pena de cada réu em 1/3, o que perfaz 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa para PAULO SÉRGIO; e de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no tocante a ALEXSSANDRO. Não há causa de diminuição de pena a considerar.

O valor do dia-multa, ante a aparente situação econômica dos acusados, será calculado no valor unitário mínimo e deverá ser atualizado nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338).

Para início de cumprimento de pena, fixo o regime FECHADO para o cumprimento da pena de cada réu.

É o adequado para a consecução das finalidades da sanção penal, considerada a prática ininterrupta de crimes (principalmente os patrimoniais), circunstância apta a demonstrar que os réus fazem da ação delitiva o meio vida, o que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Cumprе salientar a inexistência da relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, sendo certo que a prática REITERADA de crimes patrimoniais pelos acusados, reincidentes, denota conduta social inteiramente avessa aos preceitos que presidem a convivência social, sujeitando o agente à modalidade mais severa.

Cumprе destacar que ambos os acusados cumpriam pena em regime aberto quando voltaram a delinquir. Ademais, beneficiados com a liberdade provisória nestes autos (págs.46/48), posteriormente foram presos em flagrante (Paulo Sérgio em 08/04/22 por tráfico de droga e Alexssandro por furto, cf. cópias de págs.102/108 e 121/127,

crimes pelos quais estão presos).

Desse modo, a fixação de regime mais favorável ou de qualquer outra benesse (CP, arts.44 e 77), a par de ausentes os requisitos legais, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a subtração de coisa alheia móvel.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar os réus:

a) ALEXSSANDRO PEREIRA VIANA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV (concurso de agentes), do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo.

b) PAULO ROGERIO JUSTINIANO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV (concurso de agentes), do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Os réus responderam ao processo soltos. Estão presos por outros crimes. O delito foi praticado sem violência e grave ameaça à pessoa e não foi formulado pedido expresso, pela acusação, para a prisão preventiva dos acusados. Poderão apelar em liberdade.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome de cada réu no rol dos culpados, expedindo-se guia de execução definitiva;

b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação dos réus, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;

c) Calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, os réus para que efetuem o pagamento.

Custas pelos réus, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, § 9º, "a", da Lei nº. 11.608/03, cuja exigibilidade está suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

P.I.C

São Bernardo do Campo, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA